

1500262-70.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... de acordo de não persecução penal. Tráfico que supostamente viria a ser considerado privilegiado. PGJ que, provocada pelo juízo nos termos do art. 28-A CPP, manteve a recusa do Promotor de Justiça. Posição institucional que deve ser preservada. ORDEM DENEGADA." (TJSP, HC nº 2064200-84.2020.8.26.0000, Rel. Xisto Rangel, j. 05.05.20). g.n.

No mérito, a acusação procede em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500262-70.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500262-70.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON FERREIRA BATALHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

WELLINGTON FERREIRA BATALHA e JOSÉ SEVERINO DE SOUZA foram denunciados por incursão no § 1º e nos incisos I, II e IV do § 4º do artigo 155 do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 28 de janeiro de 2021, por volta das 20h17, na rua Guido Montegia, 120, Centro, nesta cidade e comarca de Mauá, os acusados, previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraíram, para proveito comum, 04 mochilas, 28 maços de cigarro marca Eight, 16 ferramentas diversas descritas no laudo de fls. 144/148, 18 cartuchos intactos e 5 deflagrados juntamente com um envelope, um notebook marca Apple modelo Macbook A1370, 10 aparelhos de celular de marca diversa, 14 simulacros de arma de fogo, 3 munições, duas de calibre 32 e uma de calibre 380, 9 facas, uma luneta de precisão, um micro celular, um ipod, um carregador de calibre 380, uma balança de precisão, 4 frascos de perfume, 2 cartuchos de calibre 38 em embalagem

do IC, 2 projéteis deflagrados juntamente com embalagem do IC, 8 cartuchos deflagrados de calibre 380 juntamente com embalagem do IC, todos sob custódia da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Recebida a denúncia, o feito foi suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fl. 278).

Posteriormente, réu Welligton foi citado (fl. 293) e apresentou resposta à acusação.

Desmembrou-se o feito para o corréu José Severino (fl. 321).

Durante a instrução, as testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas. Por fim, procedeu-se ao interrogatório do réu.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a parcial procedência da ação penal, afastando-se a qualificadora do rompimento de obstáculo, enquanto a Defesa insiste no cabimento de proposta de acordo de não persecução penal. No mérito, busca a absolvição ou, ao menos, a fixação das penas nos patamares mínimos, reconhecendo-se a atenuante da confissão, sob regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É a síntese do necessário.
Decido.

Destaca-se, inicialmente, que o acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do réu, mas ato discricionário do Promotor de Justiça. No mais, diante da recusa do Ministério Público, os autos foram remetidos ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do §14 do art. 28-A do Código de Processo Penal, que insistiu na recusa de oferta do referido acordo (fls.309-19).

Ressalta-se que o acordo de não persecução penal não pode ser imposto pelo Judiciário em caso de recusa do Ministério Público. Neste sentido precedentes do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Acerca do acordo de não persecução penal, trata-se de uma discricionariedade do Ministério Público, eis que o artigo 28-A do Código de Processo Penal dispõe que: 'Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)'. Ou seja, trata-se de um dispositivo legal não vinculante, não devendo o Poder Judiciário interferir na obrigatoriedade de sua aplicação." (HC 2026314-51.2020.8.26.0000, Rel. Ricardo Sale Júnior, j. 05.04.20). g.n.

"Habeas Corpus. Insurgência quanto à ausência de propositura de acordo de não persecução penal. Tráfico que supostamente viria a ser considerado privilegiado. PGJ que, provocada pelo juízo nos termos do art. 28-A CPP, manteve a recusa do Promotor de Justiça. Posição institucional que deve ser preservada. ORDEM DENEGADA." (TJSP, HC nº 2064200-84.2020.8.26.0000, Rel. Xisto Rangel, j. 05.05.20). g.n.

No mérito, a acusação procede em parte.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-2), boletim de ocorrência (fls. 07-11), auto de exibição e apreensão (fls. 12-4), fotografias (fls. 45-62), laudo pericial do local (fls. 138-43), laudo pericial dos objetos

(fls. 144-215) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

Interrogado, na fase administrativa, o réu Wellington negou a acusação. Sustentou que (sic) "é morador de rua há dois anos e dorme defronte a edificação do local dos fatos há cerca de um mês. É usuário de crack há cerca de um ano e sustenta seu vício coletando material para reciclagem e cuidando de veículos que estacionam pelas cercanias. Na data dos fatos havia acabado de chegar ao local, ocasião em que José, seu conhecido, lhe disse que havia ganhado algumas coisas e queria lhe mostrar. Nesse momento a Polícia os abordou" (fl. 05).

Sob o contraditório, inovou e admitiu a subtração na companhia do corréu José. Disse que, na ocasião, pularam o muro, mas não quebraram a parede (mídia digital).

Os policiais militares, na fase inquisitiva, historiaram que (sic) "faziam patrulhamento de rotina pela comarca de Mauá, ocasião em que, passando pelas antigas instalações do 1º Distrito Policial da Cidade, avistaram dois indivíduos, ora identificados como Wellington Ferreira Batalha e José Severino de Souza, o primeiro, portando uma mochila. Ao avistar a viatura policial, Wellington foi até o local onde dormem, na calçada, junto a um muro e deixou ali a mochila. Fundada a suspeita, efetuaram a abordagem. De pronto, José afirmou que haviam acabado de furtar alguns pertences do interior da edificação para vender em seguida. Em seguida, apontou o local onde estariam tais pertences, acondicionados em quatro mochilas, juntamente no local onde Wellington havia deixado a que estava em seu poder. Wellington negou que tivesse furtado os bens, dizendo não saber se sua origem" (fls. 03-4).

Em juízo, o policial militar Lucas reiterou que durante patrulhamento de rotina visualizaram Wellington com uma mochila. Ao visualizar a viatura, ele e outro rapaz dirigiram-se até o local onde dormiam e deixaram a mochila. Considerando que o local era próximo da delegacia, suspeitaram daquela atitude e decidiram pela abordagem. Localizaram com os acusados outras quatro mochilas. Informalmente, José admitiu o furto, dizendo que eles pularam o muro do antigo 1º DP e subtraíram aqueles bens. Pelo que se recordou, uma parede estava quebrada, mas não soube informar se foram os acusados que a quebraram (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha o entendimento do Pretório Excelso:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Inicialmente, descabida a alegação da Defesa quanto à ilegalidade na busca pessoal, uma vez que os policiais militares que realizaram a abordagem afirmaram que, nas proximidades da antiga sede do 1º Distrito Policial, visualizaram o réu Wellington na companhia de José, trazendo consigo uma mochila e, assim que visualizou a

viatura, guardou a mochila no local onde dormia, ocasionando a fundada suspeita para a busca pessoal.

Também não há que se falar em atipicidade da conduta sob alegação de erro sobre elemento constitutivo do tipo penal ("coisa alheia"). Evidente que os bens subtraídos não eram coisas abandonadas como sustentado pela defesa.

Cumprе salientar que em momento algum do seu interrogatório o réu diz acreditar que estava subtraindo bens abandonados (mídia digital).

No mais, o local era a antiga sede do 1º Distrito Policial que, embora desativada, estava devidamente fechada e sob custódia da Polícia Civil, tanto que o réu Wellington e o acusado José tiveram que pular o muro para acessar o seu interior. Não bastasse, o fato de o imóvel estar supostamente sem manutenção, com (sic) "mato alto e [...] diversos sacos pretos (de lixo) amontoados, além de muita sujeira" (fl. 371), não indica necessariamente que estava abandonado. Ora, evidente que os objetos que ainda guarneciam o interior da antiga Delegacia de Polícia (fls. 45-62) não são res derelictae.

Nesse sentido, decidiu o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES TENTADO – Pleito de absolvição insuficiência de provas ou por erro de tipo – Impossibilidade – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Réu confesso quanto à subtração – Depoimentos de policiais aos quais se confere relevante valor probante – Réu detido na posse da 'res furtiva' – Inversão do ônus da prova – Alegação de ausência de dolo por erro de tipo ao empalmar coisa que entendia estar abandonada que não pode ser acolhida – "Animus furandi" evidenciado – Ademais, abandono da coisa que não se presume, sendo imprescindível que esteja patente a intenção de o proprietário da 'res derelicta' renunciar ao bem – Condenação mantida – Penas corretamente impostas – Pretendido reconhecimento da confissão – Desacolhimento – Admissão parcial dos fatos que não foi utilizada pela magistrada sentenciante como elemento de convicção a fundamentar a condenação – Não incidência da Súmula 545, do STJ – Redução máxima em razão da tentativa – Inadmissibilidade – 'Iter criminis' percorrido pelo agente que muito se aproximou da consumação, o que autoriza apenas a mitigação média imprimida em primeiro grau – Regime aberto e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos corretamente impostos – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1503383-89.2019.8.26.0536; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/10/2022; Data de Registro: 13/10/2022).

Apelação criminal. Furto. Tentativa. Erro de tipo. Coisa abandonada. Res derelicta. Não se há de acolher a arguição da tese do erro de tipo, referente à sustentação de que se pensou cuidar de coisa abandonada, quando, para acessá-la, o agente teve que certamente romper cadeado que guarnecia o acesso ao local. (TJSP; Apelação Criminal 0020565-73.2016.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/07/2017; Data de Registro: 31/07/2017).

As qualificadoras do concurso de agentes e da escalada restaram comprovadas pela prova oral colhida e pelo laudo pericial de fls. 138-43, notadamente as fotografias de fl. 140.

Por outro lado, necessário afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo. Embora o laudo pericial ateste a existência de (sic) "um vão de aproximadamente 60cmx80cm suficiente para permitir a passagem de uma pessoa de compleição física média", não há nos autos elementos seguros a demonstrar que o réu e seu comparsa foram os responsáveis pelo rompimento.

Assim, comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto duplamente qualificado, de rigor a condenação.

Passa-se à dosagem das penas.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, diante da multiplicidade de qualificadoras, sendo que o concurso de agentes foi utilizado para qualificar o crime e a escalada para exasperar a reprimenda, perfazendo, 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa. Neste sentido:

"(...) O apelante foi beneficiado com a fixação da pena base no piso legal, haja vista a multiplicidade de qualificadoras, sendo que, uma delas poderia ter sido utilizada para qualificar o crime e, as demais, para exasperar a reprimenda básica". (TJSP, Apelação Criminal nº 1500815-20.2021.8.26.0540, Rel. Des. FERNANDO SIMÃO, j. 16.03.22).

"APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA - CONFISSÃO E DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL AMPARADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS - PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA - UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA PARA QUALIFICAR O CRIME E OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - PENA-BASE - FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 DO CP DESFAVORÁVEIS - REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO - POSSIBILIDADE DEVIDO À REINCIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. A confissão e a delação extrajudicial, amparadas nos depoimentos das testemunhas e nos demais elementos dos autos, formam prova robusta para condenação. Não caracteriza bis in idem a utilização de uma das qualificadoras para qualificar o crime do furto duplamente qualificado, e outra como circunstância judicial. Impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, diante das circunstâncias do artigo 59 do CP desfavoráveis, o que também justifica a fixação do regime fechado para cumprimento de pena, mormente se o réu é reincidente." (TJ-MS - APR: 10350 MS 2005.010350-7, Relator: Des. Carlos Stephanini, Data de Julgamento: 07/03/2006, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/03/2006)

"HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, havendo pluralidade de qualificadoras, possível que uma seja utilizada para caracterizar o tipo qualificado e a outra como circunstância judicial desfavorável. 2. No caso, incidiam as qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de agentes, sendo que uma serviu para a tipificação do crime de furto qualificado e a outra como circunstância judicial desfavorável - motivo pelo qual a pena-base foi fixada acima do mínimo legal -, não havendo qualquer constrangimento ilegal ocasionado ao paciente. 3. Ordem denegada." (STJ - HC: 202035 SP 2011/0070113-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 02/06/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2011).

Na segunda etapa, tendo em vista que a confissão foi relevante para o deslinde do feito, a pena retorna ao patamar mínimo de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

O valor do dia-multa será o unitário mínimo.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a sanção corporal por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena imposta, atendendo-se, na execução, o disposto no art. 46 e

parágrafos do Código Penal, e prestação pecuniária à entidade beneficente a ser indicada pelo Juízo das Execuções, no valor de 1 (um) salário mínimo, sem prejuízo da multa já fixada.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para CONDENAR o réu WELLINGTON FERREIRA BATALHA, qualificado nos autos, às penas de 02 anos de reclusão, sob regime penitenciário aberto, e 10 dias-multa, no unitário mínimo, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na forma acima especificada, por incursão nos incisos II e IV do parágrafo 4.º do art. 155 do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Defere-se os benefícios da justiça gratuita (fl. 381).

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA